



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro Robson Marinho

Tribunal Pleno – **SEÇÃO ESTADUAL**

Sessão: **18/9/2024**

Exame Prévio de Edital – **Referendo e Julgamento**

E-001: TC-018652.989.24-5

Representante: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.

Representada: Penitenciária de Franca – Secretaria de Estado da Administração Penitenciária

Responsável: Anderson Manoel Faria, Autoridade que subscreveu o edital

Assunto: Edital do Pregão Eletrônico nº 90009/2024 da Penitenciária de Franca – Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para o período de 01 de setembro a 31 de outubro.

Valor Total Estimado: R\$ 180.709,12

Advogados cadastrados no e-TCESP: Luis Henrique Garcia (OAB/SP 322.822)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. MENOR PREÇO POR ITEM. ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. CONSULTA RESPONDIDA PELO E. TRIBUNAL PLENO NOS PROCESSOS TC-25129.989.20, TC-25128.989.20 e TC-25130.989.20. RESPOSTA À PERGUNTA Nº 10. IMPROCEDÊNCIA. CESSADOS OS EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR.

Relatório

Trata-se de representação intentada por Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90009/2024 da Penitenciária de Franca – Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para o período de 01 de setembro a 31 de outubro.

Insurge-se a Representante, em suma, contra disposição que estabelece a participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

porte e cooperativas nos 22 itens licitados, nos termos do art. 48 da Lei Complementar 123/2006 – item 3.5.1¹ do edital -.

Numa apertada síntese, alega que: - a Administração desmembrou o quantitativo anual a ser adquirido em seis certames a serem realizados durante o ano, em desconformidade com o art. 40 da Lei 14.133/2021; – há ilegalidade de se utilizar o estimativo de dois meses para tornar o certame exclusivo para participação de ME/EPP/Cooperativas; e - não houve a justificativa nos termos do art. 49 da Lei Complementar 123/03.

É nesses termos que requereu a sustação cautelar do certame e a retificação do ato convocatório.

O edital é datado de 22/8/2024 e a sessão pública estava designada para a data de 6/9/2024.

Por decisão publicada no Diário Oficial Eletrônico de 9/9/2024, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi determinada a sustação cautelar do certame licitatório e fixado prazo de 10 (dez) dias para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

Em resposta, a Penitenciária de Franca apresentou cópia do ato convocatório e documentação pertinente, bem como suas alegações e justificativas.

A respeito do prazo de vigência do contrato ser de 2 (dois) meses, aduziu que foram enviadas mensagens da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado para a Penitenciária de Franca

¹ “3.5.1 Para os itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 e 22 a participação é exclusiva a microempresas de pequeno porte e cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021 (se admitida a participação de cooperativas neste item 3), nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

informando que só seria repassado recurso para a aquisição de gêneros alimentícios para o período de 2 (dois) meses, de maneira a entender que a decisão pelo período não foi opção da Unidade Prisional.

Sob outro aspecto, alegou que o limite de R\$ 80.000,00 do art. 48, I, da Lei Complementar 123/06 não foi ultrapassado por nenhum dos itens que compõem o objeto. Menciona o “*Parecer Subg-Cons nº 151/2017*”, da Procuradoria Geral do Estado, o qual apresenta em anexo.

Por fim, afirma não haver mais estoque suficiente dos produtos alimentícios para que possa a Unidade Prisional suprir necessidades relacionadas à alimentação de detentos e do quadro funcional.

A Procuradoria da Fazenda do Estado e Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência, em suma, por desconformidade do edital com o art. 40 da Lei 14.133/2021 – “*Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: [...]*”.

É o relato do necessário.

npg



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

VOTO

TC- TC-018652.989.24-5

Preliminarmente, submeto ao referendo deste e. Plenário decisão em que foi determinada a sustação cautelar do edital do Pregão Eletrônico nº 90009/2024 da Penitenciária de Franca – Secretaria da Administração Penitenciária, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para o período de 01 de setembro a 31 de outubro.

No mérito, esclareço que, num primeiro momento e, considerando o quadro apresentado na representação, no que era possível pelo rito célere do exame prévio de edital, promovi a suspensão do certame por entender que, a princípio, havia elementos a justificar tal ato.

Entretanto, com o advento de outras representações da mesma empresa Representante contra vários editais de outras unidades prisionais do Estado, conforme processos TC-18691.989.24, TC-18755.989.24, TC-18758.989.24, TC- 18793.989.24, TC-18794.989.24 e outros, verifiquei aspectos que ensejaram uma revisão de posicionamento que levou ao arquivamento daquelas representações, e que agora se tornam base para um juízo de mérito sobre a matéria em apreciação.

É que neste rito sumário e de cognição não plena não há como prosperar a queixa sobre a periodicidade das compras realizadas, o que não está direcionado ao texto do edital propriamente dito, mas a uma estratégia de compras da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, ao serem realizadas, pelas unidades prisionais, várias licitações durante o ano para a aquisição de gêneros alimentícios estocáveis.

Isso recai sobre um ato de gestão, e não propriamente sobre os regramentos do presente instrumento convocatório, o que torna o exame prévio de edital instrumento inadequado para tanto.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

De qualquer maneira, esse juízo de mérito é exarado sem prejuízo de consignar **recomendação**, a qual penso deva ser dirigida à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, por ser prática disseminada em praticamente todas as unidades prisionais. Há de ser consignada **recomendação**, pois, à **Secretaria de Estado da Administração Penitenciária**, para que as compras de produtos alimentícios estocáveis pelas unidades prisionais passem a estar lastreadas em planejamento realizado nos termos do “caput” do art. 40 da Lei 14.133/2021, considerando a expectativa de consumo anual:

“Art. 40 - O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: [...]” (sublinhado acrescido).

Corroborando tal providência a informação da Penitenciária de Franca no sentido de que não há mais estoque suficiente de produtos alimentícios para que possa aquela Unidade Prisional suprir necessidades relacionadas à alimentação de detentos e do quadro funcional, o que se mostra como um efeito aparentemente danoso da ausência de um planejamento de compras baseado na expectativa de consumo anual.

Prosseguindo, está a questão diretamente ligada ao art. 48, I, da Lei Complementar 123/06 - “I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)” -.

A Lei Complementar 123/2006 inovou ao estabelecer benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em processos licitatórios, e os regramentos afetos a esse tema foram objeto de interpretações diversas e que sofreram sedimentação de entendimento no tempo, o que é natural no âmbito do Direito. E esta Corte, obviamente, integrou esse processo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

E é nesse cenário que está a impugnação voltada contra o item 3.5.1² do edital, que dispõe sobre a participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que atendam ao disposto no art. 34³ da Lei 11.488/2007, na disputa pelos 22 (vinte e dois) itens aqui licitados sob o critério do menor preço por item.

Numa abordagem inicial, a interpretação acerca da hipótese legal de aplicação do mencionado benefício, do art. 48, I, da Lei Complementar 123/06, defendia a tese de que o limite legal de R\$ 80.000,00 teria como referência o valor global do certame, a exemplo dos processos TC-5509.989.15, TC-5540.989.15, TC-5724.989.15, TC-5828.989.15 e TC-5836.989.15.

Não obstante, tal entendimento foi revisado e aprimorado por meio da Consulta respondida por este e. Tribunal Pleno no âmbito dos processos TC-25129.989.20, TC-25128.989.20 e TC-25130.989.20, de onde extraio, como trecho de interesse, a resposta dada à pergunta nº 10, que solve a matéria aqui apreciada:

“Pergunta nº 10: As licitações públicas realizadas por itens de valores individuais inferiores a R\$ 80.000,00, porém com valor global, representado pelo somatório dos itens, superior a tal valor, devem ser exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte?”

Resposta: O artigo 48, I, da LC nº 123/06 impõe a exclusividade de participação das microempresas e das empresas de pequeno porte nos certames compostos por itens de contratação iguais ou inferiores a R\$ 80.000,00. O sentido da expressão ‘itens de contratação’, por sua vez, é esclarecido na redação do artigo 6º do Decreto nº 8.538/15 (aplicável na ausência de legislação local específica e mais favorável sobre a matéria), que a direcionou para os ‘itens’ ou ‘lotes’ autônomos sujeitos à licitação, destacando-se para exclusividade aqueles cujos valores sejam de até R\$ 80.000,00.

² “3.5.1 - Para os itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 e 22 a participação é exclusiva a microempresas de pequeno porte e cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021 (se admitida a participação de cooperativas neste item 3), nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006.”

³ “Art. 34 - Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no [inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#), nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o disposto nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida Lei Complementar.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Todavia, tal como na Pergunta nº 6, essa resposta sinaliza mudança de entendimento jurisprudencial e somente produzirá efeitos na apreciação dos atos sujeitos ao controle deste Tribunal praticados a partir do trânsito em julgado desta decisão.”

(Tribunal Pleno, TC-25129.989.20, TC-25128.989.20 e TC-25130.989.20, Rel. Cons. Sidney Estanislau Beraldo, Sessão de 21/7/2021, DOE de 27/8/2021, trânsito em julgado em 21/9/2021)

À vista, pois, de tal deliberação deste e. Tribunal Pleno, não há retificação a ser realizada quanto ao disposto no item 3.5.1 do edital, na medida em que não há qualquer sinal de que algum dos 22 (vinte e dois) itens licitados tenha valor total estimado que transponha o limite de R\$ 80.000,00 do art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006.

Ante o exposto, voto pela **improcedência** da representação e **declaro cessados** desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada, autorizando a Penitenciária de Franca a prosseguir com o procedimento licitatório, sem prejuízo do envio de **recomendação** à **Secretaria de Estado da Administração Penitenciária**, para que as compras de produtos alimentícios estocáveis pelas unidades prisionais passem a estar lastreadas em planejamento realizado nos termos do “caput” do art. 40 da Lei 14.133/2021, considerando a expectativa de consumo anual.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimada a Penitenciária de Franca, na forma regimental.